

노동관행 소고(小考)*

— 통상임금 산정관행을 중심으로 —

신 권 철**

목 차

- I. 노동관계와 관행
- II. 노동관행의 개념과 규범력
- III. 통상임금 산정관행
- IV. 결론

I. 노동관계와 관행

1. 문제의식

한 근로자가 누군가의 지시로 일을 하면서 보수를 받는다는 ‘사실’은 근로계약이라는 ‘의사표시’보다 더 많은 것을 전해준다. 그리고 그러한 사실이 반복될 경우 그 둘의 관계는 계속적 법적 관계들로 구성된다. 이 글은 ‘노동관계!’에서 반복된 사실들의 효력’을 논하고자 한다. 아래의 사례에서 우리는 노동법적으로 무엇을 발견할 수 있을지 먼저 살펴본다.

투고일 2013.11.08, 심사일 2013.12.02, 게재확정일 2013.12.11

* 본 논문은 2013. 11. 5. 대법원 노동법실무연구회에서 발표한 글(노동관행 소고 - 임금지급관행을 중심으로)을 일부 수정·보완한 것이다.

** 서울시립대학교 법학전문대학원 부교수

1) 본 글에서는 노동관계를 개별적 근로관계 및 집단적 노사관계를 포함하는 개념으로 사용한다.

A 사례 :「근로자 甲은 1993년부터 20년간 크리스마스 이브에 사용자 회사로부터 단체협약이나 취업규칙, 근로계약에 없는 크리스마스 보너스를 매년 100만 원씩 받았다. 甲은 2013. 12. 24. 크리스마스 보너스 100만 원을 받을 권리가 있을까?」

B 사례 :「근로자 乙은 박사학위 취득 후 2006년부터 자신의 학위 취득 해당 분야 기술연구소에서 매년 1년 단위로 연구원으로 근무하는 계약을 체결하여 매년 같은 내용의 근로계약을 7회 동안 반복갱신하였다. 乙은 2013. 11. 20. 연구소로부터 계약 갱신을 거절당하였다. 乙은 연구소의 갱신 거절을 부당하다고 다툼 경우 승소할 수 있을까?」

두 사례는 노동관계에서 흔하게 발생하는 임금지급관행과 인사관행을 보여준다. 위의 사례에서 크리스마스 이브의 보너스와 근로계약의 반복 갱신은 명시적인 취업규칙이나 근로계약으로 설명하는 것이 사실상 불가능하다. 그러나 위 사례에서 甲은 2013년에 크리스마스 보너스에 대한 청구권이 생길 것 같고, 乙에게도 갱신기대권이 생길 것 같다. 그리고 위와 같은 관행이 사업조직 내 근로자들에게 모두 반복되는 일이라면 2013년에 새로 취업한 다른 사람들도 같은 취급을 받을 수도 있을 것 같다. 이것은 위 관행이 개별적 근로계약을 넘어서는 것이 될 수 있음을 암시한다. 이하에서는 우리가 왜 甲이나 乙에게 청구권이나 기대권이 발생할지 여부를 확정적으로 대답할 수 없는지 그 이유를 살펴보고자 한다.

2. 사실 또는 규범으로서의 노동관행

1) 관행의 기능은 무엇인가?

당사자들 사이의 구체적 법률관계에서 법이나 계약을 적용 또는 해석하는데 있어 반복된 사실인 관행은 어떤 역할을 할 것인가? 로마법에서부터 관행(관습)은 최고의 법해석자(Optimus legum interpres consuetudo)로 여겨졌다.²⁾ 즉, 법이 없거나 모호할 때 관행은 법을 해석

2) 이 로마법의 격언은 법이 어떤 부분에서 침묵하고 있을 때 실제로 법에 의해

하거나 보충한다. 법 뿐만 아니라 계약도 당사자간에는 지켜야 하는 법이 되므로 계약이 없거나 모호할 때도 관행은 계약을 해석하거나 보충한다.

2) 노동관행의 기능은 무엇인가?

노동관계에서 노동관행³⁾이 단순한 사실로서만 기능하는 것이 아니라 규범으로서 기능하는 것을 우리는 판례를 통해서도 확인할 수 있다. 예컨대, 사용자의 근로자에 대한 급여지급의무의 발생근거가 되는 예시로서 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약 외에 판례는 ‘노동관행’도 사용자의 의무발생의 근거로 보고 있다.⁴⁾ 그 밖에 판례는 근로자의 동의 없이 사용자가 행하는 일방적 전직(轉籍)의 ‘인사관행’은 원칙적으로 허용하지 않고 있다.⁵⁾

위와 같이 노동관행이 어떤 경우에는 일정하게 반복된 사실로부터 규범적 효력(사용자에게 임금을 지급할 의무)을 발생시키기도 하고, 어떤 경우에는 일정하게 반복된 사실만으로는 규범력(근로자가 자신의 동의 없이도 사용자의 전직에 응할 의무)을 발생시키지 않기도 한다. 위와 같

주어진 방향과 어긋나지만 않는다면, 관행(usage)이 그 결함을 보충할 수 있고, 법이 모호한 의미의 언어를 사용할 때 오랜 기간 동안 그 법 아래서 이루어져 온 것들이 불확실성을 줄이는 해석을 제공해 줄 수 있다는 의미이다 (Herbert Broom, *A Selection Of Legal Maxims*, The Eighth Edition, Sweet And Maxwell, London, 1911, 532쪽).

- 3) 김유성 교수는 ‘노사관행’(노동관계에서 계속·반복적으로 행해짐으로써 노사간의 행위준칙으로 인정되는 것)이라는 표현을 쓰고(김유성, 『노동법 I』, 법문사, 2005, 14쪽), 김형배 교수는 ‘노동관행’(경영 내에서 동일한 행태 또는 습부가 사실적으로 여러 차례 아무 유보 없이 반복되는 경우)이라는 표현을 사용하고(김형배, 『노동법』, 제22판, 박영사, 2013, 103쪽), 임종률 교수도 ‘노동관행’(노동관계 현장에서 근로조건, 직장규율, 시설관리, 조합활동 등에 관하여 장기간 반복·계속된 처리방법)이라 하고 있다(임종률, 『노동법』, 제11판, 박영사, 2013, 10쪽).
- 4) 대법원 1999. 2. 9. 선고 97다56235 판결, 대법원 1999. 5. 12. 선고 97다5015 전원합의체판결, 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결 등.
- 5) 대법원 1993. 1. 26. 선고 92누8200 판결, 대법원 1993. 1. 26. 선고 92다11695 판결, 대법원 2006. 1. 12. 선고 2005두9873 판결.

이 노동관행이 어떤 경우에는 단순한 사실만으로 남아있고, 어떤 경우에는 그것을 뛰어넘어 규범력을 가지기도 한다.

앞서 본 근로자 甲에게 100만 원의 보너스를 받을 권리가 있다고 하면 그것은 바로 20년 간의 노동관행에 대해 규범력을 인정하는 것이다. 기존의 매년의 보너스 지급관계는 묵시적 합의 등으로 의사표시 해석의 방법으로 해석해 낼 수 있지만, 미래의 지급의무를 규율하는 관계는 양 당사자의 묵시적 합의를 쉽게 도출해 낼 수 없고, 묵시적 합의라는 것도 결국은 의제이고, 기존의 사실들로부터 추단하는 것이다. 이렇게 당사자의 의사표시 해석의 한계지점, 즉 계약이 더 이상 힘을 쓰지 못하는 지점에서부터 노동관행은 자신의 독자적 기능을 발휘한다.

3. 법과 계약, 그리고 노동관행

1) 법과 계약

법은 노동관행을 배제하거나 변화시킬 수 있다. 계약 또한 노동관행을 배제할 수 있다. 노동관행은 원칙적으로 국가의 법이나 당사자들의 합의가 없거나 모호한 부분에서만 존재한다. 장시간 노동관행이 근로기준법의 법정근로시간들을 위반할 수 없으며, 종신 고용관행이 노사 당사자의 근로계약기간의 합의를 무효화시킬 수 없는 이유는 법과 계약이 존재하는 공간에서 관행의 규범력은 철회되기 때문이다. 그러나 법과 계약이 존재하는 공간에서도 장시간 노동관행과 종신 고용관행은 사업조직 내에서 사실로서는 계속 존재한다. 우리는 그래서 노동관행과 규범력을 구별해야 한다.

2) 기간제법을 통해 본 노동관행의 변화

(1) 기간제법 제정과 노동관행의 변화

법(판례를 포함)은 노동관행을 변화시킨다. 예컨대, 2007년 시행된 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하, ‘기간제법’이라 한다)은 2년의 사용기간을 초과하여 기간제 근로자를 사용하는 경우 기간의 정함

이 없는 근로자로 전환시킨다. 기간제법 시행 이전에는 이러한 사용자의 사용기간 제한(근로자보호 목적)규정이 없었기 때문에 많은 사업체가 기간 제한 없이 근로계약기간을 반복갱신하는 관행이 있었다. 그러나 기간제법 시행 이후로 사용자들은 근로계약을 통하여 기간제 근로자는 2년만 사용한 후 근로관계를 종료시키거나 심사를 거쳐 정규직(무기근로계약직)으로 전환하는 방식을 택하고 있다. 현실은 정규직 전환(약 5.8%)보다 2년 후 근로관계가 종료되는 상황(2년 내 이직·기간만료 52.7%)이 약 9배 가량 더 많이 발생하고 있고, 이직자의 근속기간은 평균 2.1년이다.⁶⁾ 이러한 현실 앞에서는 반복갱신되던 근로계약이 앞으로도 반복갱신되리라는 보장은 사회적으로 사라진다. 기간제근로의 반복갱신에 대한 기대나 예전은 일부 예외를 제외하고 이제 노사 당사자들 모두에게서 사라지게 되었다.

(2) 판례의 변화

판례도 위와 같은 노동관행의 변화에 반응한다. 과거와 달리 기간제법 시행 이후 법원이 기간제 근로자들의 갱신기대권을 축소하여 이해하게 된 것도 바로 이러한 사회적 현실(2년 후 정규직 전환이 아니라 근로관계가 종료되는 다수의 상황)과 당사자들의 예견가능성(2년 뒤 근로관계가 종료되리라는 예견가능성)으로부터 정규직 전환의 기대나 계속고용의 기대 같은 것을 도출해 내기는 어렵다는 점을 반영하고 있다. 즉, 기간제 근로자는 2년이 가까워질수록 기간제법이 보장하는 무기계약직으로의 전환기대보다도 현실의 사용자가 대응하는 방식인 근로관계의 종료의 예견이 더 높아지는 것이다. 그런데 우리의 입법자는 과연 그것을 예견하지 못했을까?

4. 노동관행의 생성과 사업조직

1) 노동관행의 생성이유

6) 고용노동부, 고용형태별 근로자패널조사 8차(2012. 4. 기준) http://laborstat.molab.go.kr/newOut/menu07/menu08_intro.jsp (2013. 11. 10. 최종방문).

노동관행은 왜 만들어지는가? 그것은 법과 계약이 노동관계의 전부를 규율하지 않기 때문이다. 그것은 일부러 그렇게 한 것이기도 하고, 불가능한 것이어서 그렇게 된 것이기도 하다. 예컨대, 사용자의 인사관리에 대해 근로기준법이나 노동조합 및 노동관계조정법(이하, ‘노동조합법’이라 한다)은 별다른 규율을 하지 않고 있고, 근로계약도 별다른 내용을 담지 않는 경우가 많다. 근로자의 업무에 대해서도 대부분의 근로계약은 구체적인 내용을 담고 있지 않다. 왜 이런 법적·계약적 공백의 부분들을 그냥 놔 두는 것일까? 거기에는 두 가지 이유가 있다고 본다.

하나는, 사용자의 인사관리나 노무지휘에 사실상 사업조직 목적의 자율권을 부여하기 때문이다. 즉, 경영·인사업무지시 등은 사용자의 권한이고, 거기에 법이나 계약을 침투시키는 것은 어렵기도 하거니와 사업의 효율성을 저해할 수도 있기 때문이다. 우리는 사용자에게 의해 일방적으로 정해지는 취업규칙이 왜 만들어졌는지, 사실상 근로자에게 큰 이해가 결린 인사관리규정이나 근무평정규정의 작성권한은 어디에서 나오며, 취업규칙은 왜 규범성을 띠게 되는지 찬찬히 살필 필요가 있다.⁷⁾

7) 대법원은 근로기준법 제96조 소정의 취업규칙의 개념을 “명칭에 구애받음 없이 사용자가 근로자의 복무규율과 임금 등 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 규정한 것”으로 보고 있고, 그 법적 성격은 “사용자가 정하는 기업 내의 규범”으로 보고 있다. 취업규칙이 효력을 발생하는 방법과 관련해서는 “신설 또는 변경된 취업규칙의 효력이 생기기 위하여는 반드시 같은 근로기준법 제13조 제1항에서 정한 방법에 의할 필요는 없지만, 적어도 법령의 공포에 준하는 절차로서 그것이 새로운 기업 내 규범인 것을 널리 종업원 일반으로 하여금 알게 하는 절차 즉, 어떠한 방법이든지 적당한 방법에 의한 주지가 필요하다”고 하고 있다(대법원 2004. 2. 12. 선고 2001다 63599 판결). 정리하면, 대법원은 취업규칙이 근로자의 근로조건을 정하는 기업 내 법규범으로 작용하고, 그 제정권한은 사용자에게 있고, 그 공포방식은 종업원 일반에게 알리는 것(주지시키는 것)이라 이해하고 있다. 그런데, 독일과 같은 경우는 “19세기 후반 사용자가 일방적으로 작성하는 취업규칙(Arbeitsordnung)제도는 1934년 나치시대 사업장규칙(Betriebsordnung)으로 변경되었으며, 1952년 사업조직법(Betriebsverfassungsgesetz)을 제정하면서 사업장규칙(취업규칙)은 폐지되고 노사간에 공동으로 결정하는 공동결정제도가 도입되었다”(방준식, “독일 공동결정제도의 성립과 발전”, 『법학논총』 제24집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2007, 4-5면). 이러한 과거의 독일의 취업규칙법제가 사용자의 사업장 내 일방적 권력행사를 법적으로 승인해 준 것이

다른 하나는, 조직적·계속적 법률관계가 가지는 특성 때문이다. 근로자가 사업조직에 편입되어 자신의 역할을 지속적으로 해야 하는 경우 계약의 한 당사자로서의 측면보다 사업조직 내 조직원으로서의 측면이 강화되고, 업무와 관련하여 조직과 관련된 내부규율들이 외부의 법이나 당사자간 계약과 무관하게 독립적으로 작동하게 된다. 또한 근로관계는 계속적 법률관계로서 구체적인 지시와 이행의 내용을 특정하기도 어렵고, 그 내용도 계속 변화하기 때문에 법과 계약의 내용이 그에 구체적으로 대응해 변화되기도 어렵다.⁸⁾

2) 사업조직 내 규율과 노동관행

위와 같이 사업조직 내 규율과 관리권한에 기하여 조직 내부적으로 인사보수조직관리 등에 관한 규정을 정하는 경우 그것은 법도, 계약도 아니고 사실상 취업규칙으로 보기 어려운 경우(내부결재만 맡고 시행되는 여러 가지 규정들)도 있다. 그러나 그러한 내부적 지침 등에 따라 시행되는 근무평정, 보수규정, 인사규정들이 그 자체로는 규범성을 가지기 어렵더라도 노동관행으로서 규범력을 인정받게 될 여지는 있다.

사업조직 내 인사관리나 업무지시에 대해서는 조직 내부의 자율성과 사용자의 권한을 보장하려는 경향이 있는데, 그 영역에는 계약과 법보다는 관행과 사업조직의 자율성이 뒤섞여 있다. 계약과 법이 없는 곳, 즉 자율성과 관행이 뒤섞인 사업조직 영역에서 사용자의 권한이 시작되고, 그 권한이란 자의적이다. 노동관행은 사용자의 이러한 권한을 보장하는 것이 될 수도 있고, 어떤 경우에는 이 권한을 제한하는 것이 될 수도 있다.

3) 노동관행의 적용대상자

사업조직의 운영관행은 원칙적으로 조직 내 근로자 모두에게 적용되는

라 이해하는 견해가 있다(방준식, 앞의 논문, 5쪽).

8) 片岡 교수도 노동관행이 발생하는 이유를 “노동법 영역은 노동관계가 복잡하고 동적이기 때문에 법령이나 단체협약, 취업규칙 외에 각종의 노동관행에 의해 노동관계가 규정되고 있다”고 본다(片岡 昇, 『노동법』, 송강직 역, 삼지원, 1994, 78쪽).

것이다. 예컨대, 앞의 사례에서 甲의 회사가 20년 간 크리스마스 이브에 보너스를 전 사원에게 주는 노동관행이 있어왔다면 20년 간 그것을 받아 온 甲 외에 2013년 초 새로 들어온 신참 직원인 丙도 보너스를 받을 것을 기대할 수 있다. 또한 7회 근로계약을 반복갱신한 乙의 연구소가 연구원과의 계약을 반복갱신하는 관행이 있어왔다면 2012년 입사한 丁 연구원도 반복갱신의 기대가능성이 있다. 이처럼 노동관행은 단순히 개별 근로자와의 관계에서만 문제되는 것이 아니라 그가 속한 사업조직 전체의 근로자와의 관계에서도 문제가 된다.

5. 노동관행의 규범력

노동관행의 규범력은 법원에 의해 창설되는 것인가? 아니면 확인되는 것인가?⁹⁾ 앞서 맨 위에서 본 사례에서 회사의 근로자 甲에게 크리스마스 보너스에 대한 청구권이 생기고,¹⁰⁾ 연구소의 근로자 乙에게 근로계약 갱신에 대한 기대권이 생긴다고 법원이 인정하는 경우 그것은 계약의 해석 등을 통해 기존의 권리를 확인하는 것 일수도 있지만, 반복된 보너스 지급관행이나 반복된 근로계약의 갱신관행을 통해 근로관계의 당사자 사이에 일정한 규범력을 부여해 준 것일 수도 있다. 즉, 법원은 노동관행에 대해 권리의무 관계를 창설하는 규범력을 부여할 수 있다.

노동관행이 그 자체로 규범력을 얻고 있는지, 없는지는 법원이 선언해 주기 전까지는 알 수 없다. 앞서 본 甲의 보너스와 乙의 계약갱신은 과거의 관행일 뿐이고, 미래는 예측할 수 없다. 그 관행이 멈추어서 일방에 의해 다투어질 경우에 그것을 공적으로 확인해 줄 수 있는 권위는 법원

9) 관습(법)의 확인은 “이론상으로는 확인이지만 실천적으로는 권위 있는 심급(사법기관)의 확인을 통한 창출로 이해할 수 있다”는 점에 대해서는 최병조, “로마법상의 관습과 관습법”, 『서울대학교 법학』 제47권 제2호, 서울대학교 법학연구소, 2006, 18쪽.

10) 독일연방노동법원은 “크리스마스 상여금을 아무 유보 없이 3회 계속 지급하면 지급의무를 지켰다는 의사가 있는 것으로 보며, 근로자의 승낙은 상여금의 수령에 의하여 추단된다”고 보았다(BAG vom 17.4.1957, AP Nr.5 zu §616 BGB Gratifikation)(김형배, 앞의 책, 103쪽 주 3)에서 재인용).

밖에 없다. 즉, 노동관행은 그것이 깨어질 때 비로소 자신의 모습을 드러낸다. 그리고 노동관행에 규범력을 부여하는 자, 노동관행의 규범력을 선언하는 자는 법원이다.

II. 노동관행의 개념과 규범력

1. 노동관행의 개념

노동관행을 어떻게 개념지을 것인지는 두 가지 측면에서 바라보아야 한다. 하나는 민법에서 말하는 관습법 또는 사실인 관습과 다른 특성을 부여할 수 있는지라는 외적인 경계로서의 개념 구분이고, 다른 하나는 내적인 개념 정립으로서 노동관행 자체에 규범력이라는 개념 요소를 부여할지 여부이다.

1) 관습법, 사실인 관습과 노동관행

(1) 관습법과 사실인 관습

먼저, 민법 제1조의 관습법과 제106조의 사실인 관습과 노동관행을 어떻게 연결시킬 수 있을지 문제된다. 통설¹¹⁾과 판례¹²⁾는 대체로 관습법을 “사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이른 것”을 의미한다고 한다. 또한 사실인 관습은 다수설¹³⁾과 판례¹⁴⁾가 “사회의 관행에 의하여 발

11) 박윤직, 『민법총칙』 제7판, 박영사, 2002, 17쪽(관행과 법적 확신 또는 인식을 관습법의 개념요소로 보고 있다); 김증한·김학동, 『민법총칙』 제10판, 박영사, 2013, 14면(관행의 형성과 법적 확신의 획득을 관습법의 개념 요소로 보고 있다).

12) 대법원 1983.6.14. 선고 80다3231 판결(호주의 가족 분묘에 대한 권리귀속 여부); 대법원 2003. 7. 24. 선고 2001다48781 전원합의체 판결(구 관습 중 상속회복청구권의 존속기간 20년 여부); 대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 판결(여성의 중원지위 인정).

13) 박윤직, 앞의 책, 226쪽, 김증한·김학동, 앞의 책, 345쪽.

생한 사회생활규범인 점에서 관습법과 같으나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인된 정도에 이르지 않은 것”으로 관습법과 차이를 두고 있다.

(2) 판례의 노동관행 개념

노동관행에 대해 대법원은 두 가지 의미로 사용하고 있다. 하나는 “기업내부에 존재하는 특정한 관행”이라는 사실로서만 의미지우는 경우이고,¹⁵⁾ 다른 하나는 “노사간에 당연한 것으로 여겨질 정도의 관례가 형성된 것”이라는 노사간의 규범적 의식을 강조하는 경우이다.¹⁶⁾ 대법원은 전자의 경우에는 규범력을 발휘하지 못하지만, 후자의 경우에는 규범력을 발휘할 수 있다고 한다.

(3) 학계의 노동관행 개념

학계에서는 ① 노동관행, 노동관습(사실인 관습), 노동관습법을 준별하려 하거나, ② 노동관행의 개념 자체에 관행적 사실 외에 노사 쌍방의 규범의식을 설정하여 그에 따른 법적 효력을 부여하려 하거나, ③ 법적 효력이 있는 노동관행(사실인 관습인 노동관행)과 그러한 효력이 없는 노동관행(사실인 관습이 아닌 노동관행)¹⁷⁾을 구분하기도 한다.

14) 대법원 1983.06.14. 선고 80다3231 판결.

15) 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000다50701 판결(“기업의 내부에 존재하는 특정한 관행이 근로계약의 내용을 이루고 있다고 하기 위하여는 그러한 관행이 기업 사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나 기업의 구성원에 의하여 일반적으로 아무도 이의를 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여져서 기업 내에서 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범의식에 의하여 지지되고 있어야 한다”).

16) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000다18127 판결(“사용자에게 근로의 대상성이 있는 금품에 대하여 그 지급의무가 있다는 것은 그 지급 여부를 사용자가 임의적으로 결정할 수 없다는 것을 의미하는 것이고, 그 지급의무의 발생근거는 단체협약이나 취업규칙, 급여규정, 근로계약에 의한 것이든 그 금품의 지급이 사용자의 방침이나 관행에 따라 계속적으로 이루어져 노사간에 그 지급이 당연한 것으로 여겨질 정도의 관례가 형성된 경우처럼 노동관행에 의한 것이든 무방하다”).

17) 이달휴, “노동관행의 성립과 효력”, 『재산법연구』 제24권 제1호, 2007, 한국재

(4) 노동관행 개념의 특성 - 사업조직 내 규율

노동관행은 민사상의 관습법과 어떤 다른 특성이 있을까? 민사상의 관습법이 주로 과거로부터 내려오는 종중제도, 상속분 등 가족 내 관습, 분묘기지관·관습법상의 법정지상권과 같이 사회 내 관습들에서 그 모습을 드러내는 반면, 노동관행은 한 기업이나 사업조직 내부와 같이 특정한 조직공동체 내에서 노사간의 역관계에 의해 자율적으로 생성되는 경우가 많다. 예컨대, 과거 노조전임자에 대한 임금지급 관행, 파업시 임금지급 관행 등은 모든 사업장에서 발생하는 것이 아니라 특정한 사업장에서만 발생한다.

다음으로, 노동관행은 그 규범력의 수범자가 계약의 당사자적 지위에서 그 효과를 받을 뿐만 아니라 단체법적·조직법적 지위에서도 그 효과를 받는다. 즉, 계약과 단체(조직)의 양자의 지위에서 노동관행의 영향을 받는다. 예컨대, 앞서 본 甲이나 乙은 보너스 지급 또는 계약의 반복갱신을 통해 노동관행이 영향을 미칠 뿐만 아니라 기업(사업조직) 자체의 전체 근로자에 대한 임금지급관행·노무관리관행을 통하여도 영향을 받는다. 반복갱신의 경험이 없는 근로자(앞서 본 丙, 丁)에게도 노동관행이 영향을 미치게 되는 이유도 그 때문이다.

2) 노동관행의 개념 정립

노동관행을 어떻게 개념정립하느냐?의 문제는 그 개념요소로서 반복된 사실 외에 규범적 의식(규범력)을 포함하여 이해할지의 문제, 다시 말하면 사실인 관습처럼 이해할지 아니면 관습법처럼 이해할지가 문제이다. 통상 민법에서는 관행 자체는 객관적 사실로서만 구성하고, ‘사회구성원들의 법적 확신(규범적 의식)’은 주관적 요건으로 하여 관습법의 성립을 인정한다.

(1) 관행 對 관습 - 관행

먼저, 노사관계 내부에서 이루어져 온 관행을 일정한 사회 내에서 오

랫동안 이어져 내려온 생활방식이나 습관으로서 말하는 관습이라 하기는 어렵기 때문에 일정한 사업조직 내에서 노사간에 되풀이된 행위로서의 의미로 노동관행이라는 표현을 쓰기로 한다.

(2) 사실 對 의사 - 사실

다음으로, 노동관행은 개별적 근로관계나 집단적 노사관계에서 나타나는 반복된 사실들에 중점을 둔다. 그 이유는 개별적 근로관계에서는 근로자의 종속성으로 인해 양 당사자의 의사표시를 통한 계약 등이 형식화와 불평등의 요소가 있고, 집단적 노사관계에서는 개별 당사자들의 의사보다 집단적·단체적 규율이 강조되므로 의사보다는 사실이 해석에 있어 중요한 영향을 가진다. 이는 근로자 개념 등에서 객관적 사실을 중심에 놓고 판단해야 하는 이유와 같다. 따라서 노사간의 규범적 의식이나 규범력을 가지는지 여부와 상관없이 노동관행은 사업조직 내에서 노사간에 되풀이된 사실적 행위들만으로 개념구성을 하기로 한다.¹⁸⁾ 다만 그러한 사실적 행위들이 노사당사자의 향후 기대나 예견 등의 행위패턴을 변화시킬 수 있지만, 여기서는 노동관행을 구성하는 주관적 요소로서 파악하지 않는다.

2. 노동관행이 규범력을 발생하기 위한 근거와 요건

1) 규범력 발생근거

노동관행이 일정한 요건하에서 규범력을 발생시킬 수 있다면 ‘그 근거는 어디에서 찾아야 할 것인가?’가 문제가 된다.

¹⁸⁾ 임종률 교수는 노동관행 그 자체는 특별한 법적 효력을 가지지 않지만, 당사자들 사이에 이의 없이 계속되어 온 경우 묵시적 합의나 사실인 관습으로 보아 근로계약 등의 한 내용이 될 수 있다고 본다. 김형배 교수도 노동관행은 규범의식에 의하여 지지되고 있는 사실을 의미하는 것이어서 노동관행 자체가 규범력을 가지는 것은 아니라고 한다(김형배, 앞의 책, 105면). 독일 내에서는 노동관행을 사실로 보는 견해와 규범력을 가진다는 견해가 대립하고 있다고 한다(김형배, 앞의 책, 105쪽 주석 1) 재인용).

(1) 학설

일반적으로 학설을 분류해 볼 것 같으면, 노동관행의 구속력의 근거를 크게 ① 계약설(목시적 합의설, 사실인 관습설), ② 규범설(불문의 취업규칙설, 경영상 관습법설 포함), ③ 신뢰책임설¹⁹⁾으로 구분할 수 있다²⁰⁾.

위의 각 학설을 간단하게 설명하면, ① 계약설은 노동관행에서 나타난 자발적 급부의 반복된 사실로부터 향후의 법적 의무의 부담과 이를 승낙하는 상대방의 의사가 목시적으로 표현되었다고 간주하여 근로계약의 한 내용으로 된다고 보는 것이며, ② 신뢰책임설은 일정하게 반복된 행위들로부터 추단되는 기대와 신뢰를 보호할 필요성이 있고, 이는 신의칙이나 배려의무에 근거한다고 설명하고 있으며, ③ 규범설은 계약적 성격보다 노동관행을 단체협약이나 취업규칙 등과 나란한 독자적인 법원(法源)으로 보거나, 노동관행을 불문의 취업규칙이나 경영상 관습법으로 보아 법규범처럼 직접적, 강행적으로 적용된다고 본다.

그리고 위와 같은 노동관행의 구속력의 근거에 따라 노동관행의 근로조건형성규범으로서의 위치를 단체협약, 취업규칙, 근로계약 중 ① 불문의 취업규칙으로 취업규칙과 동등한 효력을 가진다고 하는 견해, ② 근로계약과 동등한 효력을 가진다고 하는 견해 등으로 나뉘기도 한다.

(2) 노동관행의 독자적 규범력 필요

개인적 생각으로는 노동관행 자체는 객관적 사실로서만 의미를 가지고, 규범력이 발생하는 것 자체는 반복된 사실을 통해 얻은 기대와 예견이 가지는 법적 힘에 주안을 두어야 한다고 본다. 학설이나 판례가 기존의 법적 효력의 발생근거들(단체협약, 취업규칙, 근로계약)로 편입시키려는 노력은 어찌보면 노동관행을 독립한 또 다른 규범력 발생근거로 보지 않으려는 태도로 이해된다. 그러나 노동관행의 최초 발생 연원이 노사간 합의(단체협약이 아니다),²¹⁾ 사용자의 일방적 지침(취업규칙이 아니다),

19) 김형배, 앞의 책, 104쪽.

20) 학설의 보다 자세한 내용은, 권오성, “노사관행의 법적 성질에 관한 일고찰”, 『변호사』 제34집, 서울지방변호사회, 2004, 187-195쪽; 권 혁, “노동관행에 따른 급부청구권의 형성과 소멸”, 『노동법학』 제23호, 한국노동법학회, 2006, 279쪽을 참조.

개별 근로자의 묵시적 동의(근로계약이 아니다) 등으로 이루어질 수는 있으나 위 각 발생연원은 실질적으로 노동관계의 규범력 발생근거(단체협약, 취업규칙, 근로계약) 어디에도 해당되지 않는 경우가 많다.

이렇다 보니까 판례나 학설 중에는 단체협약이나 취업규칙, 근로계약으로서의 형식적 요건을 갖추지 못한 채 장기간에 걸쳐 시행되어 온 것들에 대해서도 그 자체로 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등으로서 일용 규범력을 발생시킨다고 간주하는 사례들(예컨대, 사용자의 일방적 내부지침이나 결정을 취업규칙으로 해석하거나²²⁾, 노사협의회에서 결정한 사항을 단체협약처럼 이해하거나²³⁾, 취업규칙의 불이익 변경에서 근로자의 집단적 동의를 얻지 못한 경우 사회통념상 합리성으로 집단적 동의를 대신하는 사례²⁴⁾)이 발생한다.

-
- 21) 대법원 2005. 10. 13. 선고 2004다13755 판결(“원심이 피고 회사는 단체협약에 따라 원고들을 포함한 전 직원들에게 매년 설 휴가비, 추석휴가비 각 150,000원, 하기휴가비 250,000원을 각 지급하여 왔고, 노사합의에 따라 선물비를 연 200,000원 상당으로 책정한 후 그에 상응하는 선물을 현품으로 지급하여 온 사실을 인정하고, 위 각 휴가비 및 선물비는 단체협약, 노사합의 및 관행에 따라 일률적·계속적·정기적으로 지급된 것으로서 그 월평균액이 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 포함된다고 판단한 것은 정당하다”).
- 22) 대법원 2005. 5. 12. 선고 2003다52456 판결(“기아자동차판매가 기아그룹 차원에서 자구계획서를 작성하면서 그 자구계획서 내에 기아그룹이 정상화될 때까지 기아그룹 소속회사의 임직원들의 상여금·휴가비 등을 반납하는 방침을 정하여 그 내용을 서면화하였으므로 위 자구계획서는 종업원의 근로조건변경을 내용으로 하는 것으로서 취업규칙에 해당한다”).
- 23) 대법원 2005. 3. 11. 선고 2003다27429 판결(“노동조합과 사용자 사이에 근로조건 기타 노사관계에 관한 합의가 노사협의회 협의의 거쳐서 성립되었다 하더라도, 당사자 쌍방이 이를 단체협약으로 할 의사로 문서로 작성하여 당사자 쌍방의 대표자가 각 노동조합과 사용자를 대표하여 서명날인하는 등으로 단체협약의 실질적·형식적 요건을 갖추었다면 이는 단체협약이라고 보아야 할 것이다”).
- 24) 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009다32362 판결(“당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 여전히 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그의 적용을 부정할 수는 없다”).

우리 판례가 1) 임금지급의무의 발생근거로 단체협약, 취업규칙, 근로계약 외에도 노동관행(사용자의 방침이나 관행)을 별도의 지급의무 근거로 명시하고 있는 점²⁵⁾, 2) 규범력 있는 노동관행이 있다면 근로자 동의 없는 전적의 인사관행도 허용될 수 있다고 보는 점을 고려해 볼 때 노동관행이 일정한 요건을 갖춘 경우라면 독자적 규범력을 발생하는 근거가 될 수 있다고 생각한다. 다만, 앞서 본 바와 같이 노동관행의 발생계기는 사용자의 일방적 지침이나 결정이 될 수도 있고, 노사간의 합의가 될 수도 있으며, 근로자들의 묵시적 동의로도 될 수 있는 것이다.

2) 규범력 발생요건

법의 세계에서 노동관행이 의미 있게 되기 위해서는 그것이 일정한 법적 효과를 발생시켜야 한다. 우리는 법적 효과를 발생시키는 행위는 계약이나 단독행위와 같은 법률행위만을 알고 있기 때문에 원칙적으로 법률행위가 아닌 노동 자체가 어떤 법률효과를 발생시키는지 알지 못한다. 그러나 자세히 살펴보면 노동 자체가 가지는 법적 효과들, 예컨대 해고 제한을 통한 노동보호, 2년 기간제 근로시 무기근로계약으로의 전환과 같이 노동 자체는 스스로를 보호하거나 연장시키는 법적 효과들을 부여받고 있다. 그렇다면 노동관행 또한 일정한 법적 효과들을 발생시키는 규범력(甲의 사례에서 보너스 지급청구권의 발생, 乙의 사례에서 갱신기대권의 발생)을 가지기 위해서는 어떤 요건이 필요한지 구체적 분석을 할 필요가 있다. 개인적 생각으로는 노동관행이 규범력을 발생하기 위해서는 1) 적극적 요건으로 노동관행으로부터 당사자들의 기대나 예견이 가능할 것(규범의식), 2) 소극적 요건으로 강행법규나 단체법질서에 위반되지 않을 것이 필요하다. 즉, 노동관행의 규범력은 사업조직 내 당사자들 사이에 규범의식이 생긴다고 하더라도 그것이 강행법규나 단체법질서에 위반될 경우에는 규범력 자체가 발생하지 않는다.

(1) 노동관행으로부터 일정한 절차준수나 권리에 대한 기대나 예견이

²⁵⁾ 대법원 1997. 5. 28. 선고 96누15084 판결 등.

가능할 것(규범의식)

관행은 그 행위당사자들과 조직 내에서 계속 그러할 것이라는 신뢰를 부여한다. 노동관행은 노사 양측 중 어느 한 쪽의 유불리로 연결되는 경우가 많기 때문에(예컨대, 앞서 甲의 크리스마스 보너스나 乙의 갱신기대권) 한 쪽은 신뢰를 없애려는 의사가 있고, 다른 한 쪽은 신뢰를 유지하려는 의사가 있다. 즉, 대립되는 이해관계의 장에서 공통적인 법적 확신의 성립은 어렵지만,²⁶⁾ 적어도 기대나 예견을 통한 규범의식의 성립은 가능하다.

노사간 소송상 분쟁해결의 핵심은 노사 당사자의 의사를 규명하는 것이라기보다 어찌 보면 사업조직이나 그 구성원의 신뢰를 보호하려는 노력에 있다. 그래서 법원은 늘 양 당사자의 의사 외에도 실체적 정당성에 대한 가치판단(근로자인지 여부²⁷⁾, 해고의 정당한 이유²⁸⁾, 무기근로계약 여부²⁹⁾, 갱신기대권³⁰⁾)의 자료 중 하나로서 과거 사용자가 그 당사자나

26) 片岡 昇, 앞의 책, 78면.

27) 대법원 2009. 10. 29. 선고 2009다51417 판결 등(“근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다”).

28) 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001두10455 판결 등(“해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 행하여져야 그 정당성이 인정되는 것이고, 사회통념상 당해 근로자와의 고용관계를 계속할 수 없을 정도인지의 여부는 당해 사용자의 사업의 목적과 성격, 사업장의 여건, 당해 근로자의 지위 및 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 이로 인하여 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다”).

29) 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011두24361 판결(“기간을 정한 근로계약을 작성한 경우에도 예컨대, 단기의 근로계약이 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우 등 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 당사자의 진정한 의사, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정되는 경우에는 계약서의 문언에도 불구하고 사실상 기간의 정함이 없는 근로계약을 맺었다고 볼 것”).

30) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결(“근로계약의 내용과 근로계약이

근로자들에게 반복적으로 행한 행위나 조치 등도 참고하게 된다.

판례 중에는 노동관행에 의하여 사용자에게 임금지급의무가 부과될 수 있다고 본 사례들이 있으나,³¹⁾ 위 판례만을 보고서 노동관행이라는 사실 자체에 규범력을 부여한 것으로 보기는 어렵다. 노동관행의 성립에 관한 일반론을 설시한 근로자 동의 없는 전적의 인사관행을 부정한 판례들을 보면 위와 같은 동의 없는 전적의 인사관행이 근로계약의 내용으로 되기 위해서는 1) 그 관행이 그(전적 관련) 법인체들 내에서 일반적으로 근로 관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나, 2) 그 구성원들이 일반적으로 아무런 이의도 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상의 제도로서 확립되어야 한다고 보고 있다.³²⁾

위 판례의 내용을 보면 규범력의 승인은 결국 노동관행이 근로관계를 규율하는 “규범적 사실로 조직 내 구성원들 사이에 승인되어 제도화”되었느냐? 라는 것인데, 이는 결국 법원이 최종적으로 확인하게 되지만, 그것은 사실상 조직 내 구성원들의 규범적 의사들(규범의식)을 확인하고 거기에 법률효과로서 법원이 규범력을 부여해 주는 것이 된다. 우리는 그동안 사법기관이 규범의식의 승인을 통해 일정한 규범력을 창설하는 모습을 어렵지 않게 보아 왔다.

필자가 규범력 부여의 요건으로 표현한 ‘절차준수나 권리에 대한 기대와 예견’은 노사의 반대되는 이해관계 때문에 한 쪽은 기대(신뢰)하고, 다른 쪽은 기대(신뢰)하지는 않지만 적어도 ‘예견’할 수 있는 상황일 경우라도 노동관행의 규범력을 인정할 수 있다는 의미이다. 예컨대,甲이 올해 크리스마스 보너스를 못 받고, 이후 5년 간 같은 상황이라면 2019

이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다”)

31) 주 5)의 대법원 판결들 참조.

32) 주 6)의 대법원 판결들 참조.

년에는 甲 스스로도 보너스를 못 받을 것이라 예견하게 되는 것(기대가 아니다)을 말한다.

(2) 강행법규나 단체법질서에 위반되지 않을 것

노동관행은 그것의 불법여부를 따지지 않고, 근로자나 사용자의 유불리를 따지지 않는 객관적인 사실만으로 구성된다. 근로기준법을 위반한 장시간 노동관행, 기간제법을 적용하지 않고서 행하는 근로계약의 반복 갱신관행, 징계관행, 임금지급관행 등 근로관계와 노사관계에서 일어나는 모든 관행을 포함한다.

그러나 노동관행에 규범력을 부여하는 것은 다른 의미이다. 규범력이 부여된다는 것은 노동관행을 지키고 따라야 하며, 그것을 위반할 경우 일정한 법적 제재효과가 있게 된다. 따라서 노동관행에 규범력이 부여되기 위해서는 전체 법질서와의 조화가 필요하게 되고, 결국 노동관행은 국가의 법과 노사간의 단체법 질서에 부합되어야 한다. 대법원이 2005년 여성의 종중원 지위를 인정한 사례에서도 “사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기 위해서는 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 않는 것으로 정당성과 합리성이 있다고 인정”되어야 함을 강조하고 있다.³³⁾

또한 노동관행이 당사자의 절차적 권리를 침해하는 경우라면 규범력을 부여하기 어렵다. 판례도 앞서 본 바와 같이 회사간 전적에 있어 근로자의 동의를 받지 않고 행하는 관행³⁴⁾이나 징계절차에서 상벌위원회 등의 사전심의절차 규정이 단체협약 규정에 있음에도 불구하고 이를 생략하는 관행 등에 대해서는 규범력을 부여하지 않고 있다.³⁵⁾ 이러한 판례의 태도는 일정한 관행을 이유로 의사결정과정에서 타방 당사자의 절차적 권리를 침해하는 것을 막으려는 것이다.

³³⁾ 대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 전원합의체 판결.

³⁴⁾ 대법원 1993. 1. 26. 선고 92누8200 판결, 대법원 1993. 1. 26. 선고 92다11695 판결, 대법원 2006. 1. 12. 선고 2005두9873 판결.

³⁵⁾ 대법원 1995. 2. 14. 선고 94다21818 판결.

3. 노동관행의 법적 성격과 기능

1) 노동관행의 법적 성격 - 사실

앞서 보았듯이 노동관행 자체는 ‘노동관계에서 반복된 객관적 사실’로서 개념정의하였기 때문에 노동관행은 일정한 사실로서만 의미를 가진다. 그런데 민법에서 이러한 ‘사실(사실행위)’은 ‘의사(법률행위)’에 비추어 크게 중시되지 않지만,³⁶⁾ 노동법에서는 ‘의사’외에도 ‘사실’에 일정한 법적 힘을 부여한다. 근로자 개념에서 근로계약에 앞선 근로사실이 상대적으로 더 중요한 의미를 가지게 되고(판례에 의한 근로자 지위 부여), 파견근로나 기간제근로가 2년 이상 이루어질 경우 정규근로(사용사업주와의 근로 또는 무기근로)로 이행되는 것(입법에 의한 근로자지위 변경)은 노동이라는 ‘사실’이 가지는 힘에 ‘의사’가 가진 법적 효력을 일정하게 제한하고 있음을 보여준다.

2) 노동관행의 기능

민법에서는 관습법을 법 적용의 기준(민법 제1조)으로, 사실인 관습을 법률행위(당사자의 의사) 해석의 기준(민법 제106조)으로 이해한다. 또한 관습법은 물권을 창설하는 권원이 되기도 하고(민법 제185조), 각종 근린관계에서 관습은 토지소유자의 비용부담이나, 권리행사방법을 규율하는 기준이 되기도 한다.³⁷⁾

36) 민법은 법률효과가 부여되는 법률요건으로 크게 용태(Verhalten, 사람의 정신작용을 요건으로 하는 것)와 사건(Ereignis, 사람의 정신작용을 요건으로 하지 않는 것)으로 구분하고 있는데(김증한·김학동, 앞의 책, 298쪽, 박윤직, 앞의 책, 189쪽), 근로자 노동은 외부적 용태인 행위(Handlung) 중 사실행위(Realakt)에 포함될 것으로 보이나 민법에서는 그러한 노동 자체에 법적 효력을 부여하는 규정은 없다.

37) 예컨대, 토지소유자의 저수 등을 위한 공작물에 대한 공사청구권 행사시 그 비용부담(제224조), 수류지 소유자의 수류 변경방법(제229조), 용수권 사용과 승계(제234조), 경계표나 담의 설치비용(제234조), 경계선부근 건축시 이격거리(제242조), 특수지역권 사용수익(제302조)에 대해서는 관습에 의하도록 하고 있다.

생각건대, 노동관행 또한 앞서 민법이 규율하는 것처럼 사업조직 내에서의 근로조건 형성기능과 사업조직 내에서의 인사·노무·임금지급 등의 일정한 선례와 표준으로서의 준거기능을 한다. 여기서 말하는 노동관행의 기능은 규범력을 전제로 한 것이 아니라 노동관행 자체가 가지는 사실적인 기능을 의미한다.

(1) 근로조건 형성기능

사업조직 내 노동관행은 임금·해고·인사·이동 등에 있어 근로조건을 형성한다. 통상임금 산입범위를 정하는 임금(퇴직금)지급관행, 전직·정년·해고 등 인사관행, 휴일·근로·야간·근로 등 근로관행은 모두 근로자의 근로조건을 형성하는 노동관행이다. 단체협약·취업규칙·근로계약이 근로조건을 형성하는 규범력을 가진 법적 근거라는 점은 다들 여지가 없으나, 위와 같은 집단적·개별적 근로조건 형성규범 외에도 노동관행은 그것들이 규율하지 않는 영역, 기존의 근거들로부터 명시적 추가·변경 없이 추가되거나 변경되는 영역에서 근로조건을 형성하며, 노동관행이 지속될 경우 기존의 근거들을 개폐하면서까지 근로조건을 형성하기도 한다.

(2) 준거기능(통제기능)

노동관행은 사업조직 내에서 사용자나 근로자, 노동조합이 일정한 행위를 할 때 기존의 선례 또는 표준으로서 작용한다. 예컨대, 임금지급시기와 관련해 매월 20일 지급하는 관행이 10여 년간 존속되어 왔다면 미래에도 매월 20일 지급하는 것으로 당사자들이 기대 또는 예견하기 때문에 지급기일에 대해 다툼이 있다면 최종적 해석자는 기존의 임금지급시기를 관행으로 존중해야 한다. 또한 인사절차, 징계절차, 해고절차, 사유 등에 있어서도 기존에 지침·내부규정 등에 의해 반복되어 온 관행이 있다면 그 관행은 향후의 인사조치 등에 있어서도 준거로서 기능을 한다. 준거가 되는 노동관행은 노사 당사자들의 일방적·자의적 행위를 적절히 통제하는 기능을 한다.

4. 노동관행의 규범력의 내용

노동관행이 규범력을 가진다면 그 효력의 내용은 무엇일까? 그것은 세 가지(정당화 효력, 권리형성 효력, 준거적 효력)로 구분해 볼 수 있다.

1) 정당화 효력(소극적 효력)

규범력 있는 노동관행은 단체협약, 취업규칙, 근로계약 없이 행한 노사 쌍방의 급부에 대해 법적 근거를 부여하여 정당화시킨다. 예컨대, 근로자의 추가 근로시간이 관행적으로 사용자에게 의해 이루어지거나, 사용자의 추가적 보너스 지급이 관행적으로 이루어져 온 경우 그 추가 근로시간이나 보너스 지급을 수령한 당사자가 그 급부를 수령하는 것이 위법하거나 부당이익이 되지 않도록 하는 것이 노동관행이 가지는 효력 중의 하나로 볼 수 있다. 특히, 노무급부(근로)의 대가로 지급된 돈을 임금에 아니라거나 착오로 지급되었다는 이유로 취소할 경우 그에 대응하는 이미 제공된 근로는 근로자가 돌려받기 어렵다는 점에서도 기존에 지급된 근로의 대가는 계속 근로자에게 유보되어야 할 필요성이 있다. 노동관행은 급부를 보유할 수 있는 정당화 권원이 된다.

2) 권리형성 효력(적극적 효력)

사업조직 내 사용자나 근로자가 기존의 노동관행에 기대어 일정한 규범의식을 가지게 된다면 그로부터 일정한 권리가 발생할 수 있다. 앞서 본 甲의 사례에서 20년 간 크리스마스 이브에 사용자가 지급한 크리스마스 보너스가 사용자와 근로자 甲 쌍방 모두에게 매년 받거나 주어야 한다는 규범의식을 형성하였다면 그 효과로서 甲은 사용자에게 청구권이 발생하게 된다. 기존의 판례에서 노동관행을 통해 사용자에게 지급의무가 발생하는 임금이라는 것도 바로 이러한 노동관행의 권리형성 효력을 의미한다.

앞서 본 정당화 효력(소극적 효력)과 권리형성 효력(적극적 효력)의 차이점은 이렇게 이해할 수 있다. 예컨대, 앞의 사례에서 甲의 사용자가 매년 지급했던 크리스마스 보너스 100만 원이 착오 또는 원인 없이 지급된 것이라는 이유로 (부당이익) 반환을 요구할 경우 노동관행이 정당화 효력

(소극적 효력)을 발생하였다는 이유를 들어 근로자가 기존의 받은 돈의 반환을 거절하는 효과를 부여받을 수 있고, 노동관행이 권리형성 효력(적극적 효력)까지 발생한 경우라면 노동관행을 통한 사용자의 임금지급의 무가 발생하였다는 이유로 100만 원을 청구할 수도 있게 된다.

3) 준거적 효력

기존에 반복된 근로형태, 인사, 징계, 해고, 단체행동 등의 규범의식 있는 노동관행을 사업조직 내 일방 당사자의 일방적·자의적 결정으로 깨뜨릴 경우 그 결정을 무효화 또는 위법화시키는 효력을 가진다. 이것은 기존의 관행을 고수할 것이라 예상하는 노사 당사자의 규범적 의사를 보호하기 위한 것이다.

예컨대, 판례 중에는 근로자들이 회사의 요구로 관행적으로 해 오던 휴일근로를 정당한 이유 없이 집단적으로 거부하는 행위는 회사의 정상적인 업무를 저해하는 것으로 허용하지 않고, 그것을 쟁의행위로 간주하여 처벌한 사례가 있다.³⁸⁾ 이를 노동관행의 측면에서 분석해 보자면, 노동관행을 통하여 휴일근로가 회사의 정상적인 업무처럼 진행되어 왔는데, 이를 집단적으로 거부하여 근로자측의 일방의 의사로 휴일근로 관행을 깨는 것은 노동관행을 침해하는 것이어서 단체행동으로서의 적법성을 상실시키는 것이다.

또한 이와 반대로 앞서 본 판례의 근로자 동의 없는 전적의 인사관행 사례에서 만약 노사 당사자들 사이에 규범의식이 발생하여 동의 없는 전적이 규범력을 발생하였다면 그것은 사용자가 근로자 동의 없이 한 전적 처분을 합법화하게 된다.

5. 노동관행 및 그 규범력의 변화

1) 노동관행과 규범력의 구별

³⁸⁾ 대법원 1991.7.9. 선고 91도1051 판결, 대법원 1994. 2. 22. 선고 92누11176 판결 등.

노동관행은 어떻게 생성되고, 변경되며, 소멸되는 것인가? 그리고 이와 별도로 노동관행의 규범력은 어떻게 생성, 변경, 소멸되어야 하는 것인가? 앞서 노동관행은 사실로서만 파악하기 때문에 그것은 과거의 사실상태들에 대한 입증입에 반해, 노동관행의 규범력은 앞서 본 바와 같이 당사자들의 규범의식 여부에 대한 법원의 판단, 법원에 의한 효력부여인 규범력 부여에 대한 판단 등 가치적 요소들이 개입된다.

2) 노동관행의 변화

노동관행 자체는 성립, 변경, 소멸의 사실적 과정들을 거친다. 예컨대, 초기업적 관행으로는 장기종신고용의 노동관행이 점차 사라지고, 단기의 비정규고용관행이 증가하는 것, 기업(사업조직) 내에서의 노동관행으로 노사협의회에서 사용자가 근로자위원들과 임금교섭 등 근로조건을 결정하는 관행, 파업시 임금지급 관행, 계열사 전적시 동의 없는 전적조치관행 등을 예시할 수 있다. 기업 내 노동관행의 변화는 도산위기의 기업이 매년 지급하던 경영성과금을 없애는 것, 기업 내 복수노조 성립에 따라 단체교섭 관행을 변화시키는 것 등과 같이 기업 내 사정변화에 따라 노동관행이 변화하는 것을 들 수 있다.

3) 노동관행 규범력의 변화

(1) 규범력의 변화

위에서 본 노동관행은 그냥 사실인 관행일 뿐 거기에 규범력이 부여된 관행은 아니다. 규범력은 앞서 본 바와 같은 사업조직 내에서 규범의식이 발생하여야 하고, 그것이 강행법규 위반 등과 같은 법질서에 위배됨이 없어야 하며, 최종적으로 법원의 판결을 통해 승인되어야 한다.

노동관행은 앞서 본 바와 같이 변화하는 것이기 때문에 노동관행의 규범력 또한 항고불변의 것이 아니라 변경되거나 소멸될 수 있다. 이는 여성의 종중원 지위를 인정하지 않던 과거 판례(종중은 공동선조의 후손중 성년 이상의 남자를 종원으로 하여 구성되는 종족의 자연적 집단)³⁹⁾와

³⁹⁾ 대법원 1966. 7. 26. 선고 68다881 판결 등.

이를 뒤바꾼 2005년의 전원합의체 판결⁴⁰⁾의 내용(종중에 대한 사회적 인식 및 남녀 평등 등 우리사회 법질서의 변화를 변경이유로 하고 있다) 속에서도 확인할 수 있다.

여성의 종중원 지위를 인정한 판례는 사회적 인식과 법질서의 변화가 여성의 종중원 지위를 부정하는 관습법을 깨뜨렸음을 선언하였다. 그런데 문제는 판례가 선언언되기 전까지는 여성의 종중원 지위를 인정하는 관행은 아직 사회적으로 나타나지 않았다는 것이다. 위 판례가 가진 중요한 두 가지 의미는 여성을 종중원으로 인정하지 않는 기존의 관행을 깨는 것(기존의 관습의 규범력을 인정하지 않는 것) 외에도, 여성을 종중원으로 인정하는 기존의 관습은 없음에도 불구하고 남녀평등 등 법질서 전체의 입장에서 여성들 모두를 종중의 종원으로 편입시키는 법적 효과를 부여하였다는 것이다. 이로서 여성들은 종중원으로서의 권리, 의무를 획득하게 되었다.

(2) 노동관행의 규범력의 변화

가) 임금지급관행의 규범력 변화

사업조직 내에서 노동관행의 규범력은 어떻게 생성되고, 변화되는가? 이와 관련하여 독일연방노동법원의 사례는 소개할 만하다. 사례는 사용자의 관행적 상여금 추가지급을 상당한 기간(약 16년간) 이행해 오다가 그 후부터는 호의적 차원에서 지급하는 것이어서 청구권은 안 생긴다는 유보의사를 고지하면서 지급하다가(약 15년간) 이후 사용자가 그 지급금액의 일부를 감축하자 근로자들이 미지급 금액의 지급을 구하는 소송을 제기한 것이다.⁴¹⁾ 독일연방노동법원은 위 사건에서 기존의 노동관행을 통

40) 대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 전원합의체 판결.

41) 사안(BAG NZA 1997, 1007)의 내용은 다음과 같다(권혁, 앞의 논문, 293-294쪽에서 참조하여 인용함).

1. 사용자가 단체협약상 규정된 성탄절 상여금(세전임금 1개월분의 70%)에 대해 1961년 이래로 추가해 100%(원래 70%인데 30% 추가)로 아무런 유보없이 지급해 옴.
2. 사용자가 1978년 이후부터 100%를 지급하면서도 일정한 유보통지(호의적 차원에서 지급하는 것으로 향후 법적 청구권은 행사불가함을 고지).

해 형성된 근로자의 청구권이 새로운 노동관행을 통해 소멸함을 인정하였다.

한편, 우리의 경우 1961년 창사 이래로 35년 동안 한 공사(公司)에서 근로자가 퇴직하면 퇴직자에 대해 해당 연도의 단체협약이 체결되면 그 단체협약 및 개정 취업규칙의 보수규정에 따라 상승된 임금율에 따라 계산된 차액분을 재직자와 퇴직자에게 차액임금 또는 차액퇴직금으로 지급하는 임금지급관행이 문제된 적이 있다. 위 퇴직금지급관행에 대해 감사원 등의 지적으로 인하여 공사가 1997년부터 퇴직자에 대해 지급하지 않자 퇴직자가 그 퇴직금 차액분의 지급을 구하는 소송을 제기하였다.

이에 대해 원심은 위 퇴직금 차액분 지급관행을 규범력 있는 노동관행으로 인정해 개별 근로관계를 규율하는 효력이 있다고 보았으며, 이렇게 성립된 노동관행을 변경하려면 취업규칙의 변경에 준하여 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻는 등의 조치가 필요하고, 그렇지 않고 사용자가 일방적으로 노동관행에 반하여 근로자에게 불리한 조치를 취할 수 없다고 하였다.⁴²⁾

이에 반하여 대법원은 원심과 같이 퇴직자가 기대를 가지고 있다고 볼 수는 있으나, 퇴직금 지급의 원칙과 단체협약의 적용대상에 비추어 위와 같이 “단체협약이 퇴직자에게도 적용된다”는 노사관행의 전제가 되는 규범의식 자체가 성립할 수 없다는 이유로 원심을 파기하여 차액분 퇴직금 청구권이 발생할 수 없다고 보았다.⁴³⁾

생각건대, 노동관행은 규범의식과 무관하게 사실만으로 구성되어야 하고, 규범의식은 노사 당사자의 기대와 예견만으로 족하므로, 강행법규나

-
3. 사용자가 1993년부터는 단체협약에 근거해 종전 상여금에서 30%가 삭감된 70%만 지급.
 4. 근로자들이 사용자를 상대로 삭감된 30%의 상여금 지급을 법원에 청구
 5. 독일연방노동법원은 1978년 이후 반복된 호의성(지급청구 불가) 명시하에 상여금 지급으로 새로운 관행이 성립되었고, 이로 인해 1978년 이전까지 형성되어 온 노동관행은 소멸한 것으로 판단하여 종래의 노동관행에 기한 급부청구권 형성을 인정하지 않음

42) 서울고등법원 2000. 8. 10. 선고 2000나8009 판결.

43) 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000다50701 판결.

사회질서에 위반되지 않는 한 노동관행의 규범력은 인정될 수 있다고 생각한다. 위 사례의 경우 단체협약 체결 전에 퇴직한 근로자에 대해 단체협약 및 개정 취업규칙이 정한 임금인상율을 적용하여 차액분을 지급하기로 하는 관행은 재직 근로자들과 사용자 사이에 기대와 예전을 주고, 사회질서에 반한다고 보기도 어려우므로 규범력을 인정할 수 있어야 할 것이고, 이러한 노동관행을 상부기관의 지적 등을 이유로 변경하는 것은 그 정당성을 인정받기 어렵다.

독일에서는 노동관행 변경(소멸)논리의 법이론적 근거로 ‘거울이론’(청구권은 발생한 방식으로 소멸한다는 논리)와 ‘금반언의 원칙’(사용자가 행한 불이익변경에 대해 근로자들이 이의를 제기하지 않은 채 장기간 지속되어 사용자가 이를 승낙으로 이해하고 있는데 이에 반해 급부청구를 할 수 없다는 논리)를 제시하고 있다.⁴⁴⁾

나) 노조전임관행의 규범력 변화

노조전임관행은 각 기업별로 다양하게 존재해 왔는데, 그 규율은 대체로 단체협약이나 노사합의를 통해 정해져 왔다. 그런데 2010년 노조 전임자에 대한 급여지급 금지 규정이 시행되면서 각 기업별 노조전임관행은 변화가 생겼고, 판례는 “노조전임제가 사용자의 노동조합에 대한 편의 제공의 한 형태이기 때문에 전임제를 인정할 것인지는 물론 노동조합 전임자의 선임과 해임절차, 전임기간, 전임자 수, 전임자에 대한 대우 등 구체적인 제도 운용에 관하여도 기본적으로 사용자의 동의에 기초한 노사합의에 의하여 유지되는 것이므로, 전임제 시행 이후 경제적·사회적 여건의 변화, 회사 경영 상태의 변동, 노사관계의 추이 등 여러 사정들에 비추어 합리적 이유가 있는 경우에 사용자는 노동조합과의 합의, 적정한 유예기간의 설정 등 공정한 절차를 거쳐 노조전임제의 존속 여부 및 구체적인 운용방법을 변경할 수 있다”고 하였다.⁴⁵⁾ 위 판례를 보면 노동조합과의 합의 등 공정한 절차를 거치는 것이 기존의 노조전임 관행을 변화시킬 수 있는 정당성을 부여할 수 있음을 알 수 있다.

44) 권혁, 앞의 논문, 294-295쪽.

45) 대법원 2011. 8. 18. 선고 2010다106054 판결.

다) 노동관행의 규범력 변경(소멸)의 정당화 근거

생각건대, 노동관행이 노사쌍방의 기대와 예견(신뢰)을 통해 규범의식을 얻고, 그것의 효과로서 노동관계에서 권리의무화되거나 준거기준화되었을 경우라면 이를 사용자가 일방적 행위로 변경할 수는 없다고 할 것이다.⁴⁶⁾ 노동관행이 근로조건에 관한 집단적인 것이고, 그것이 단체협약이나 취업규칙 또는 근로계약에 편입된 것이라면 이를 불이익하게 변경하기 위해서는 단체협약이나 취업규칙의 불이익변경을 통해서 이루어져야 할 것이다.

또한, 노동관행이 앞서부터 관행적으로 해 오던 보너스 지급, 인사절차나 교섭절차 또는 기준에 관한 것이라면 비록 근로자나 노동조합이 권리나 권한을 가진 것이 아니라 하더라도 관행의 변경에 대해 사전고지와 협의절차를 거치는 것이 과거의 절차나 기준을 변경하는 데 정당성이나 합리성을 부여하게 될 것이다. 다만, 사용자에 의해 일방적으로 만들어진 기존의 노동관행이 변경되었을 때 이해당사자가 이의를 제기하지 않고서 변경된 관행이 지속되었을 경우라면 앞서 독일연방노동법원의 판례 태도와 같이 노동관행의 변경을 인정할 수 있을 것이다.

한편, 우리 대법원도 1989년부터 10여 년간 지급되어 온 생산격려금(350% 또는 250%의 상여금)이 1998년 경제위기 이후 지급하지 않은 회사에서, 퇴직근로자의 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 위 생산격려금을 포함하지 않은 것에 대해 위 생산격려금이 근로계약 또는 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 있는 것이어서 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당한다고 하였지만 그 이후 노사간에 묵시적 합의로 위 생산격려금을 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에서 제외하기로 하였다는 이유로 퇴직근로자들의 차액 퇴직금 청구를 기각한 사례가 있다.⁴⁷⁾ 위 판결의 의미도 결국 규범력 있는 노동관행이 노사간의 묵시적 합의를 통해 변경·소멸할 수 있음을 보여준다.

46) 같은 취지의 김형배, 앞의 책, 104쪽.

47) 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결.

Ⅲ. 통상임금 산정관행

1. 임금지급관행의 의의

1) 임금의 특성

임금은 근로자에게 매월 또는 주기적으로 반복되어 지급되기 때문에, 그리고 퇴직금은 사업조직 내에서 일정한 기준으로 각 퇴직근로자에게 지급되기 때문에 노동관행이 성립하기 쉬운 분야이다. 특히, 단체협약취업규칙·근로계약이 임금의 구체적인 내용을 정해 놓지 않고 있는 경우 규범력 있는 노동관행은 일정한 금전급부의 지급의무 여부(권리형성적 기능), 지급의 적법성 여부(준거적 기능) 등을 해석하거나 보충하는 역할을 한다.

2) 임금청구 소송의 특성

임금청구소송, 퇴직금청구소송, 최근의 통상임금 소송까지 그 분쟁의 실재를 보면 기존에 사용자가 지급해 오던 임금이나 퇴직금 지급관행이 강행법규인 근로기준법에 부합하지 않다는 이유로 근로자들의 집단적 청구가 이루어져 오고 있고, 법원의 실질적 고민은 사용자의 기존의 임금 지급관행을 깨서 근로기준법에 부합하도록 만드는 것이냐? 아니면 기존의 노동관행을 존중하는 해석을 통해 법적 안정성을 유지하는 것이냐? 라는 문제이다. 여기서 근로자의 보호나 노사 당사자의 의사존중보다 더 중요한 것은 임금지급관행(기존에 반복된 사실)에 어느 정도의 법적 힘을 부여할 것인가가 보다 중요한 문제가 된다.

최근의 통상임금 소송은 상여금을 통상임금에 포함시키는 것이 근로기준법에 부합하느냐? 부합하지 않느냐? 하는 것이 겉으로 드러난 쟁점으로 보여지지만 보다 중요한 쟁점은 노사간의 기존의 관행을 강행법규인 근로기준법을 들어 ‘깨는 것이냐? 말 것이냐?’가 더 중요한 문제인 것이다. 이와 관련해서 최근의 학자들 중 일부는 고용노동부의 행정지침에 의해 근거해 처리해 온 노동관행을 존중하여야 한다는 입장에 있는데,⁴⁸⁾ 이하

에서는 통상임금 산정관행에 대해 규범력을 부여할 수 있는지 살펴본다.

2. 통상임금 산정관행

통상임금과 관련된 문제들은 이미 많은 판례가 축적되었고, 학계에서도 크게 논쟁이 되고 있다. 여기서는 기존에 논의되었던 다른 논점들은 제외하고 통상임금 문제를 노동관행, 그 중에서도 임금지급관행의 규범력 발생 측면에서 논증해 보고자 한다.

1) 사용자의 통상임금 산정근거

2012년 대법원은 금아리무진 사건에서 근로자의 근속연수에 따른 비율을 적용하여 산정한 금액을 분기별로 지급하는 상여금을 정기적, 일률적으로 지급되는 고정적 임금인 통상임금에 해당될 수 있다고 보았다.⁴⁹⁾ 위 상여금은 고정적 상여금이어서 지급근거나 임금성 여부는 크게 문제가 되지 않고 통상임금 여부만 문제된다.

우리 기업의 다수는 위와 같은 고정적 상여금을 대부분 통상임금에서 제외시켜 왔으며, 상여금을 통상임금에서 제외시키는 근거는 크게 3가지이다.

그것은 1) 노동조합과의 단체협약 또는 노사합의를 통하여 협약에 따라 통상임금 산정범위에서 특정한 급여들을 제외하였다는 것이고, 2) 고용노동부 지침(통상임금 산정지침)⁵⁰⁾에 따랐다는 것이며, 3) 마지막으로

48) 이정, “일본의 통상임금 및 할증임금의 산정법리”, 『노동법학』 제45호, 한국노동법학회, 2013, 336쪽; 이형준, “계수당의 통상임금 산입에 대한 경영계 입장”, 『월간 노동리뷰』, 2012년 11월호, 한국노동연구원, 2012, 20쪽.

49) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91046 판결.

50) 2007년 노동부예규인 통상임금 산정지침은 통상임금의 판단기준으로 “통상임금에 포함되는 임금의 범위는 별표의 예시에 따라 판단한다. 다만, 그 명칭만으로 판단하여서는 아니되며, 통상임금의 의의, 근로계약·취업규칙·단체협약 등의 내용, 직종·근무형태, 지급관행 등을 종합적으로 고려하여야 한다”고 하였고, 별표에는 통근수당, 가족수당, 급식비, 상여금 등을 통상임금에서 제외(일정한 조건을 갖춘 경우 평균임금에는 포함)하고 있다. 위 예규는 2009. 9. 25. 일부개정되었으나 위 내용에는 차이가 없다.

사용자의 내부지침이나 결정에 따라 그러한 관행이 지속되어 왔다는 것이다.

위와 같은 근거에 의해 다수의 기업은 통상임금에서 판례가 인정하고 있는 일부 항목(고정적 상여금과 각종 고정적 수당)을 과거부터 제외하여 왔다. 판례가 바뀌어도 그것을 고수했다. 이유는 소송을 하는 근로자는 많지 않고, 근로자 재직 중에는 사실상 청구가 불가능하고, 퇴직 후에는 시효가 3년이다. 즉, 판례를 따르는 것은 경제적으로 비합리적이다. 그러한 합리성을 통해 사용자에게 누적된 돈의 액수의 일부가 지금의 통상임금소송을 통해 반환을 구하고 있는 것이다.

2) 통상임금의 개념 범주를 축소시킬 경우의 미래

(1) 통상임금 개념과 범주

현재 통상임금 지급과 관련된 쟁점 중 하나는 기존의 판례가 제시한 통상임금 개념과 범주 자체를 바꾸려는 노력이지만, 그것은 통상임금 개념이 가진 개방성과 개별 기업의 구체적 사례마다 적용될 수 밖에 없는 특수성에 비추어 볼 때 개념과 범주의 정리만으로 해결되기 어려운 측면도 있다.

(2) 근로자의 부당이득반환의무

일부 기업은 판례의 통상임금 개념 범주에 따라 고정적 수당 등을 통상임금의 범주에 포함시켜 연장근로나 휴일근로의 할증임금의 기준으로 삼아 지급해 왔다. 만약 판례가 변경되어 위 급여들은 통상임금의 범주에 포함되지 않는다고 하면 근로자들이 받은 할증임금이나 퇴직금 중 일부는 원인 없이 받은 부당이득이 될 것인가? 즉, 고정적 상여금을 통상임금의 범주에 포함시킨 판례가 근로자들에게 추가적인 임금청구권을 발생시켰듯이, 고정적 상여금과 각종 수당을 통상임금에서 제외하는 판결은 사용자에게 부당이득반환청구권을 발생시킬 수 있다. 사용자측 및 근로자측 금액의 다과는 법리적 판단의 고려요소가 아니다.

일부 견해는 “사용자가 착오로 법률·단체협약 또는 계약상의 급부의무가 있는 것으로 잘못 알고 일정한 지급을 반복적으로 계속한 경우(착

오에 의한 노동관행) 사용자가 그와 같은 의무의 부존재를 모르고 있는 한(선의인 한) 구속력을 가지는 노동관행은 성립할 수 없다”고 한다.⁵¹⁾ 이에 따르면 기존의 판례 태도가 변경될 경우 기존의 판례나 관행에 따라 근로자가 기존에 받은 임금이 착오로 과다 지급되어 부당이득반환의 대상이 될 수 있음을 의미한다. 게다가 부당이득반환청구권의 시효는 임금과 다르게 10년이다. 이것 또한 거꾸로 근로자들에게는 예상하지 않은 손해를, 사용자에게는 예상하지 않은 이득을 가져온다.

3. 사용자의 통상임금 산정 근거 문제

임금지급관행은 대체로 사용자의 주도하에 이루어진다. 특히 통상임금의 범주에 무엇을 넣을지, 말지는 사용자가 내부적 지침 등을 통해 결정하거나 노동조합이 있는 경우라면 일부에서는 단체협약을 통하여 결정해 왔다. 이를 하나하나 살펴본다.

1) 단체협약 또는 노사합의

먼저, 단체협약을 통하여 노사합의로 통상임금의 범주를 설정하였다면 그것은 정당성을 부여받을 수 있는가?

단체협약이나 노사합의와 같은 노사자치규범은 노동관계법령의 최저기준을 하회하지 않는 한도에서만 법원성이 인정된다.⁵²⁾ 판례는 통상임금의 목적과 취지에 비추어 성질상 근로기준법 소정의 임금에 산입될 수당을 단체협약이나 노사합의로 제외하는 것은 근로기준법이 정한 기준에 달하지 못하는 근로조건을 정한 것이어서 무효로 보고 있다.⁵³⁾ 이는 단체협약 또는 노사합의가 강행법규를 위배할 수 없다는 논리이다. 그 목적은 노사합의로 통상임금의 항목을 임의대로 정하게 할 경우 개별 근로자의 할증임금 등에 영향을 미쳐 실질임금의 감소를 가져올 수 있는 우

⁵¹⁾ Zöllner/Loritz/Hergenröder, ArbR, S. 62(김형배, 앞의 책, 105쪽에서 재인용).

⁵²⁾ 김유성, 앞의 책, 14쪽.

⁵³⁾ 대법원 1994. 5. 24. 선고 93다5697 판결; 대법원 2007. 6. 15. 선고 2006다 13070 판결.

려가 있기 때문이다.

2) 고용노동부의 통상임금 산정지침

다음으로, 고용노동부의 통상임금 산정지침에 따른 것이었다는 점이 사용자의 통상임금 제외 조치들을 정당화시킬 수 있는 근거가 될까?

판례는 이미 노동부의 유권해석을 따르는 것이 정당성을 부여할 수 없음을 지적한 바 있다. 대법원은 근로자가 지급받는 각종 수당에 대하여 그것이 통상임금에 해당되는지 여부를 둘러싸고 다툼이 있는 경우 최종적으로 “재판절차를 통하여 확정되어야 할 것”이라 보고 있고, 중재재정을 통하여 통상임금 여부를 “행정기관의 유권해석(노동부의 유권해석)에 따르도록 함으로써 성질상 통상임금에 포함되어야 할 수당이 통상임금에서 제외되는 결과를 초래한다면 이는 근로기준법에 정한 기준에 달하지 못하는 근로조건을 정한 것으로서 무효라고 보아야 할 것”이라 하였다.⁵⁴⁾

위와 같은 판례의 태도에 따르면 고용노동부의 통상임금 산정지침이 예시하고 있는 통상임금에 포함되지 않는 상여금과 수당들은 정말 예시에 불과할 뿐 법원을 기속할 수 없을 뿐더러⁵⁵⁾ 사용자에게도 통상임금 제외의 정당성을 부여해 줄 수 없다. 특히 대법원의 판례를 통해 통상임금 범주에 속하는 수당 등이 1990년대부터 지속적으로 확대되어 가고 있음에도 불구하고, 이에 따른 조치를 취하지 않은 것은 사용자의 노무관리의 영역에서 발생한 책임으로 보아야 한다.

3) 통상임금 산정관행

단체협약, 노사합의, 고용노동부 지침이 통상임금 제외의 정당성을 부여해 줄 수는 없더라도 그에 따라 이루어진 수년 간의 수당과 상여금을 통상임금에서 제외하는 임금지급관행은 노사 당사자 사이에 기대나 예견

⁵⁴⁾ 대법원 1997. 6. 27. 선고 95누17380 판결.

⁵⁵⁾ 대법원은 업무상재해인정기준에 관한 노동부 예규가 “그 규정의 성질과 내용이 행정기관 내부의 사무처리준칙을 규정한 데 불과한 것이어서 국민이나 법원을 기속하는 것이 아니라”고 보았다(대법원 1990. 9. 25. 선고 90누2727 판결).

을 주어 규범력이 발생하였다고 보는 것은 어떠한가?

생각건대, 통상임금 문제의 핵심은 수 많은 기업들이 지난 수년 또는 수십년 동안 고용노동부 지침, 노사 합의, 내부 지침 등에 따라 제외해 온 상여금과 수당들을 지금에 와서 근로자들에게 다시 계산하여 지급하도록 하는 것이 법적 안정성이나 정의에 부합하는가? 라는 기본적인 문제와 맞닥뜨리는 것이다. 근로자들에게는 기대하지 않은 이익을, 사용자에게는 예기치 않은 부담을 주는 문제이기 때문이다.

관행을 깨는 일은 어려운 일이다. 여성의 종중원 지위를 인정한 판례가 의미 있었던 이유는 그것이 기존의 관행을 깨고, 남녀평등이라는 헌법과 법률의 법질서에 맞게 바로잡겠다는 의미 때문이었다. 그 일로 인해 여성도 종중재산의 일부에 대한 권한과 종중운영에 대한 종중원으로서의 권한을 확보하게 되고, 남성은 여성이 가지게 된 권한만큼 자신의 권리가 축소되었을 것이다. 이하에서는 노동관행의 규범력 발생요건에 따라 통상임금 산정관행이 규범력을 가지게 되었는지 본 글의 마지막으로 검토해 본다.

4. 통상임금 산정관행의 규범력 여부

1) 통상임금 산정관행(초기업적 관행)의 성립여부

통상임금 문제를 가지고 있는 다수의 기업에서는 고용노동부 지침, 취업규칙, 단체협약, 내부지침 등을 통해 적지 않은 기간 동안 통상임금의 범주에서 상여금과 수당 등을 제외하여 할증임금이나 퇴직금을 계산해 왔다. 이는 개별기업 내에서 노동관행의 하나로 성립하였다고 볼 수 있다.

그러나 위와 같은 관행이 초기업적 관행이라 볼 수 있는지는 의문이다. 왜냐하면 우리나라가 장시간 노동관행이 있다고 하더라도 그것을 초기업적 관행으로 보아 모든 산업에서 그러한 문제가 있다고 볼 것은 아니기 때문이다. 또한, 통상임금 산정방식은 각 개별기업마다 다르고, 노사합의로 달리 정하는 기업도 있기 때문에 초기업적 관행이라 하기는 어렵다. 즉, 통상임금 산정관행 자체는 기업별로 다르게 이해해야 한다. 그

러나 통상임금 소송은 원칙적으로 개별기업의 통상임금 산정관행에 규범력을 부여할지 말지를 결정하는 문제이지만, 같은 관행을 가진 기업들 사이에서는 그 효과를 보고서 그 관행을 유지하지 말지를 합리적으로 결정해야 한다.

2) 규범의식의 성립여부

개별 기업 내에서 통상임금 산정관행은 노사 당사자 누구로부터도 의제기를 받아 오지 않았기 때문에 기업 내부의 노사 당사자 모두에게 일정한 규범의식(앞서 보았듯이 이것은 사업조직 내 사용자와 근로자의 예견이나 기대를 의미할 뿐 위법과 적법에 대한 인식과는 무관하다)을 발생시켰다고 볼 수 있다.

3) 강행법규 위반여부

통상임금 산정관행이 노동관행이며, 노사 당사자들 사이에 예견이나 기대(규범의식)가 있기 때문에 규범력(준거적 효력)이 있다고 주장하는 것은 가능할까? 부정해야 할 것이다. 먼저 앞서 본 바와 같이 노동관행은 강행법규에 위반해서까지 규범력을 발생할 수 없다. 또한 노사합의를 무효화시키는 강행법규의 힘은 노동관행도 무효화시킬 수 있다.

앞서 본 판례들이 누누이 지적하였듯이 다시 한 번 설명하면 노사간의 합의나 노동부 행정지침(또는 행정해석)으로 통상임금 산정의 기초가 되는 임금을 빼는 것은 근로기준법이 정한 “시간외, 야간 및 휴일근로에 대하여 가산수당을 지급하고, 해고근로자에게 일정기간 통상적으로 지급 받을 급여를 지급하도록 규정한 취지가 몰각”될 것이기 때문이다.⁵⁶⁾

4) 통상임금 산정 관행의 규범력 발생여부

그렇다면, 이러한 통상임금 산정관행에 규범력이 발생되어야 하는지의 문제가 지금 현재 법원이 대답하여야 할 문제이다. 2013년 초까지 대법

⁵⁶⁾ 대법원 2007. 6. 15. 선고 2006다13070 판결.

원은 일관되게 통상임금의 범주를 고정성, 일률성, 정기성이라는 통상임금의 본질로부터 추출해 왔고, 그것을 제외하는 당사자들의 합의, 노사합의, 고용노동부의 행정해석 등은 근로기준법이 정한 근로조건에 위배되는 것이라 보았다. 그 이유는 간단하다. 강행법규에 위반되는 노사합의나 지침을 허용하지 않겠다는 것이고, 그 논리대로라면 통상임금이어야 할 임금을 통상임금산정에서 제외하는 노동관행 또한 규범력을 부여받을 수 없다. 현행의 통상임금 산정관행에 대해 이러한 대법원의 지속적인 태도(강행법규 위반)가 유지된다면 현재의 임금지급관행과 장시간 노동관행을 점진적으로 변화시키는 계기가 될 수도 있을 것이고, 만약 거꾸로 판례가 변화된다면 현재의 통상임금 산정관행을 묵인하여 강화시키는 계기가 될 수도 있을 것이다. 즉, 통상임금 논쟁은 당위와 현실의 싸움이며, 대법원은 통상임금 소송을 통해 현실과 당위 중 무엇을 선택할 것인지 요구받고 있는 것이고, 본 글은 노동법이 가져야 할 당위를 논하는 것이다.

IV. 결론

노동현실은 노동관행을 만들어 낸다. 그리고 만들어진 노동관행은 법원을 통하여 노동관계법의 해석기준으로, 그리고 더 나아가 규범력을 발생시키는 하나의 근거로 작동하고 있다. 노동관계를 이해하는 또 다른 해석자로서 노동사실, 그리고 그 사실의 반복인 노동관행은 근로계약이나 단체협약, 취업규칙과 독립하여 탐색하여야 될 규범력 발생근거이다.

노동법은 평등하고, 합리적 이성을 가진 사람들이 자신 스스로의 의사로서 계약에 자기구속되는 모습만을 바라보는 것이 아니어야 한다. 그 의사의 내면에는 노동이라는 짐을 감내해야만 하는 현실이 있고, 그래서 현실의 노동관계를 계약관계로만 치환하려는 노력은 어찌 보면 실재를 외면하려는 노력이다. 근로자가 최저임금으로 계약을 체결하거나 1년의 단기근로계약을 체결하거나 퇴직금을 분할하여 받기로 약정하는 것이 어찌 모두 진정한 자신의 의사라고 쉽게 해석해 버릴 수 있겠는가? 법원이 일부 노동사건 재판(예를 들면, 근로자 여부, 단기근로계약의 반복갱신,

묵시적 근로관계의 인정, 퇴직금 분할약정 등)에서 계약 당사자들의 의사와 더불어 함께 늘 강조하는 ‘근로관계의 실질’에서 법을 발견하려 하고, 계약서를 법적 힘이 없는 무력한 형식으로만 바꾸어 놓는 것도 이러한 노동현실을 외면하지 않으려는 노력이다.

노동관행은 어떤 측면에서 본다면 기본적으로 사용자가 만들어 내는 것이다. 현실에서 사용자는 사업장의 법제정자이며 집행자이기 때문이다. 다른 규범력 발생근거(단체협약, 취업규칙, 근로계약)는 사용자 입장에서 비효율적이라 생각되는 근로자 또는 노동조합에게 협의와 동의를 구해야 한다. 그러한 동의나 협의 없이 매일매일 이루어지는 사용자의 결정(규정되지 않은 성과상여금 지급여부, 평균임금 또는 통상임금 산정)과 지침들(인사지침, 근무지침, 근무평정기준 등)도 노동관계에서 근로자의 법적 이해관계들에 영향을 미치고, 그것이 반복되면 마치 사업장 내에서의 법처럼 군림하고, 그러한 것들에 기반해 노동관행도 성립한다.

성립된 노동관행은 사업조직 내 일정한 질서의 하나로 편입되어 그것을 깨는 경우 기존의 노동관계에는 균열이 발생하고, 이해 당사자들은 소송을 통해 그 노동관행의 규범력이나 그 규범력의 소멸을 확인하려 하기도 한다.

한편, 노동관행은 그것이 규범력이 있는지 알지 못하기 때문에, 또는 노동관행 자체가 있는지 여부도 알지 못하기 때문에 늘 불안한 근거이다. 근로계약서에 써 있는 월급 100만 원과 계약기간 2년이, 계약서를 쓰지 않고 언제 해고 통지를 받을지 모른 채 과거에 그랬다는 이유로 매달 100만 원쯤의 월급과 2년쯤은 고용될 수 있다고 기대하는 것보다는 근로자에게 안정적이다. 그러나 계약서도 없는 상황이라면 노동관행을 통해서 그러한 기대라도 가지고, 그것에 규범력을 부여할 수도 있게 된다.

노동관행을 새롭게 이해하기 위해서는 노동관계, 그 중에서도 개별적 근로관계에서 양 당사자의 형식화된 계약들과 사용자의 일방화된 결정들을 노동관행과의 사이에서 어떻게 위치 지울지가 중요하다. 그것은 원래 노동조합이 근로자들의 대표로서 협상을 통하여 단체협약 등을 통해 합의해야 할 것들이지만 그러한 메커니즘이 모든 사업장에서 현실화될 수 있는 것은 아니다. 따라서 현실적 방안으로는 사업장 내 노사협의기구(예

컨대, 노사협의회)가 근로조건과 관련된 일정한 협의를 하고, 그것을 사용자가 일정한 지침으로 정하여 시행하여 반복하는 경우 그것을 노동관행으로서 인정하는 것도 한 방법이 될 수 있다.⁵⁷⁾ 이는 근로계약을 체결하거나 변경하는 데 있어 근로자가 가지는 취약성, 사용자의 취업규칙 시행을 통한 일방적 결정을 어느 정도 완화시켜 줄 수 있는 계기가 될 수 있다.

끝으로, 통상임금과 같은 임금산정 또는 임금지급과 관련된 문제는 명확성의 부재로부터 시작된다. 명확하지 않은 법규정, 해석의 여지가 많은 법규정은 결국 그것을 사업장 내에서 해석하고, 결정할 권한이 있는 자에게 재량을 주는 것이 된다. 그리고 그 재량은 자신에게 유리한 결정들로 귀착된다. 통상임금 소송, 평균임금 소송, 퇴직금 소송과 같은 차액임금의 문제는 재량적 판단의 여지들을 사용자에게 주어 놓고, 나중에 그것의 그 판단의 잘못을 탓하는 것이다. 따라서 이러한 문제를 막기 위해서는 사업장 내 결정권자의 판단이나 해석에 재량이 생길 수 없는 명확한 개념과 기준이 필요하다. 그래야만 불필요한 분쟁과 대립을 막을 수 있다.

주제어: 노동관행, 노사관행, 인사관행, 임금지급관행, 관습, 규범력, 통상임금, 평균임금, 임금

57) 신권철, “노사협의회의 법적 지위와 역할”, 『노동법연구』 제35호, 서울대 노동법연구회, 2013, 299쪽.

참고문헌

[단행본]

- 곽윤직, 『민법총칙』 제7판, 박영사, 2002.
- 김유성, 『노동법 I』, 법문사, 2005.
- 김증한·김학동, 『민법총칙』 제10판, 박영사, 2013.
- 김형배, 『노동법』, 제22판, 박영사, 2013.
- 임종률, 『노동법』, 제11판, 박영사, 2013.
- 片岡 昇, 『노동법』, 송강직 역, 삼지원, 1994.
- Herbert Broom, A Selection Of Legal Maxims, The Eighth Edition, Sweet And Maxwell, London, 1911.

[논문]

- 권오성, “노사관행의 법적 성질에 관한 일고찰”, 『변호사』 제34집, 서울 지방변호사회, 2004.
- 권 혁, “노동관행에 따른 급부청구권의 형성과 소멸”, 『노동법학』 제23호, 한국노동법학회, 2006.
- 방준식, “독일 공동결정제도의 성립과 발전”, 『법학논총』 제24집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2007.
- 이달휴, “노동관행의 성립과 효력”, 『재산법연구』 제24권 제1호, 한국재산법학회, 2007.
- 이정, “일본의 통상임금 및 할증임금의 산정법리”, 『노동법학』 제45호, 한국노동법학회, 2013.
- 이형준, “제수당의 통상임금 산입에 대한 경영계 입장”, 『월간 노동리뷰』, 2012년 11월호, 한국노동연구원, 2012.
- 최병조, “로마법상의 관습과 관습법”, 『서울대학교 법학』 제47권 제2호, 서울대학교 법학연구소, 2006.

<Abstract>

A Study on Customs in Labor Relations

- Focusing On Ordinary Wages -

Shin, Kwon-chul*

This article shows that customs in workplace labor relations have a role of creating rights or duties between employer and employee. The basic rights and duties in labor relations are largely based on employment contract, collective agreement or works rules. Nevertheless, labor relations cannot be covered with only the formal written contract or agreement.

Due to the dynamics and continuation of labor relations repeated practices become a certain standards of conduct in workplace. This practices is not a normative rule but the de facto repeated acts which can be a standard. This practices in labor relations give employer and employee anticipations and expectations and in certain conditions become the normative rules which regulate the parties concerned. But it can not be legally recognized that the practices in workplace labor relations become normative rules until the courts decides that it should be a legal norm to observe.

The supreme court in Korea have decided that the wages which are periodic, even and fixed should be included in the ordinary wages in the Labor Standards Act and the practices that employers exclude them from the ordinary wage (with the allowance of the collective agreement of the trade union) should be violated with the Labor Standards Act.

* Associate Professor, University of Seoul Law School

It is important to interpret labor relations disputes in light of the customs in workplace. This article emphasizes that the customs in labor relations can be a normative rules in terms of the expectations of the parties concerned which is not against the law.

Key words: labor practices, labor custom, labor relations, ordinary wages, employment contract